姓名：○○○　學號：○○○○○○○○

刑法總則　作業一

第一題（111 年公務人員高等考試三級考試）

甲在速限 50 km/h 的市區道路駕駛，見前方路口號誌顯示為綠燈，即踩下油門將速度提升到 80 km/h 要通過路口。不料，騎著腳踏車的 A，由於講電話不專心，竟然闖紅燈，突然橫向衝出到甲的車道上，甲剎車不及直接撞上 A，A 當場死亡。事後證明，如果甲未超速，即可及時剎車而不撞上 A。請問甲的刑事責任如何？

【擬答】

甲撞死 A 之行為，可能成立刑法第 276 條過失致死罪：

一、構成要件該當性

（一）甲對於 A 之死亡並無知與欲，不成立故意殺人罪；而刑法第 276 條設有處罰過失之明文（刑法第 12 條第 2 項），故以下審查過失犯之不法要件。本文依實務所採之新過失犯理論，於構成要件層次審查客觀注意義務之違反、客觀預見可能性與客觀迴避可能性，並輔以晚近有力說所採客觀歸責理論之觀點說明。

（二）行為與結果之條件關係：若無甲駕車撞擊之行為，A 不會死亡，二者間具條件關係。

（三）客觀注意義務之違反：注意義務之內涵，得依法令規範加以具體化。駕車上路本屬法所容許之風險，然道路交通安全規則就行車速度設有限制，甲於速限 50 km/h 之市區道路以 80 km/h 行駛，已超出容許風險之範圍，創造法所不容許之風險，違反客觀注意義務。

（四）甲得否主張信賴原則？甲係綠燈通行，A 闖紅燈突然衝出，甲或可主張其信賴其他用路人均會遵守交通規則。惟依實務見解（最高法院 84 年台上字第 5360 號原判例），行為人須自己已遵守相關交通法令並盡相當之注意義務，始得信賴他人亦能遵守交通規則。本題甲自身超速 30 km/h，且其超速正是無法及時剎車之原因，故甲不得主張信賴原則以排除其注意義務。

（五）客觀預見可能性：以理性謹慎之一般駕駛人為標準，於市區大幅超速通過路口，可能因剎車不及而撞擊突然出現之用路人，客觀上可以預見。

（六）客觀迴避可能性（義務違反關聯性）：過失犯之結果不法，須結果係因違反注意義務所造成。依迴避可能性理論，應檢驗「若行為人遵守注意義務，結果是否仍會發生」。本題事後證明，甲若未超速即可及時剎車而不撞上 A，屬於「合乎注意義務時，結果幾近確定不會發生」之情形，故 A 之死亡與甲之超速間具有義務違反關聯性。又速限規定之保護目的，正是防止車速過快以致剎車不及而撞擊他人，A 之死亡屬於該規範保護目的範圍內之風險實現，客觀上可歸責於甲；若依實務所採之相當因果關係說，超速行駛致剎車不及撞死他人，依一般經驗亦屬通常可能發生之結果，具相當因果關係。

二、違法性

本題無阻卻違法事由，甲之行為具違法性。

三、罪責

甲為具完全責任能力之成年駕駛人，依其個人能力，可以預見超速可能肇事（主觀預見可能性），亦有能力遵守速限而避免結果（主觀迴避可能性），具有罪責。

四、競合

甲僅有一個駕車撞擊之行為，侵害 A 一人之生命法益，僅觸犯刑法第 276 條一罪，並無想像競合（刑法第 55 條）或數罪併罰（刑法第 50 條）之問題。

五、結論

甲成立刑法第 276 條過失致死罪。

第二題（108 年司法人員特考三等）

甲酒駕經緩起訴處分確定後，某夜，眾多酒友為其設宴慶祝，宴畢，甲自認飲酒已作節制，雖有微酣感但應不致超標，遂不聽友人勸告駕車上路。途中，逢大雨視線不良，甲因專心於察看有無酒測攔檢致疏未開啟車前大燈，對向駕車之乙急於返家超速疾駛（速限 70 公里／小時，乙車速逾 1 百公里），由於路面多處嚴重積水，乙車打滑失控衝過雙黃線而闖入甲車車道，甲來不及反應之際兩車已然對撞。乙當場死亡，甲則重傷於駕駛座上，經警員酒測，甲吐氣所含之酒精濃度為每公升 0.35 毫克。試問：甲上述之酒駕肇事行為應如何處斷？（本案有關車輛之沒收與否無須討論）

【擬答】

一、甲酒後駕車之行為，成立刑法第 **185** 條之 **3** 第 **1** 項第 **1** 款不能安全駕駛罪

（一）客觀構成要件：本款規定「吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克……以上」而駕駛動力交通工具者，即成立本罪，屬抽象危險犯，只要行為人完成法定犯行，即推定危險存在，法官無須個案審查是否具體發生危險。甲吐氣酒精濃度為每公升 0.35 毫克，已超過法定標準，並駕駛汽車上路，客觀構成要件該當。

（二）主觀構成要件：甲「自認」不致超標，是否欠缺故意？刑法第 13 條第 2 項規定，行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，以故意論（間接故意）。甲明知自己飲酒且已有微酣感，友人亦當場勸阻，對於酒精濃度可能超標顯有預見；其「應不致超標」之想法，並無任何客觀根據支持（例如未經檢測），僅屬一廂情願之期待。依學說上之梗阻理論，行為人既可預見法益侵害之後果，原則上即推論其具備意欲，而本題並無足以推翻此一推論之具體間接證據，故甲具有本罪之間接故意。

（三）甲無阻卻違法事由；其酒精濃度 0.35 毫克，尚不致使其辨識或控制能力喪失或顯著減低（刑法第 19 條），具有罪責。甲成立本罪。

二、乙之死亡結果，甲是否應負刑法第 **185** 條之 **3** 第 **3** 項（或第 **2** 項）不能安全駕駛致人於死罪之責？

（一）刑法第 185 條之 3 第 3 項規定，曾犯本條之罪經緩起訴處分確定，於十年內再犯第 1 項之罪因而致人於死者，加重處罰；第 2 項則為一般之致死規定。二者均屬加重結果犯（刑法第 17 條），依實務見解，基本犯罪與加重結果間須具相當因果關係，且行為人對加重結果客觀上有預見可能性，始能成立（最高法院 107 年度台上字第 1836 號判決參照）。甲前經緩起訴處分確定，形式上符合第 3 項之前提，關鍵在於乙之死亡能否歸責於甲之酒駕行為。

（二）條件關係：若甲未駕車行經該處，乙車越線後未必與甲車對撞，甲之駕車行為與乙之死亡間具條件關係。

（三）風險實現與迴避可能性：酒駕規範所欲防止之風險，係駕駛人因酒精影響致注意力、反應能力下降而肇事；未開大燈所創造之風險，則是他方無法辨識本車位置。然本題乙係因自己嚴重超速（逾速限 30 公里以上）、行經積水路面打滑失控，衝過雙黃線闖入甲之車道，「甲來不及反應之際兩車已然對撞」。縱使甲未飲酒且已開啟大燈，面對突然越線且已失控之乙車，仍無從閃避，屬於「合乎注意義務時，結果幾近確定依舊發生」之情形，欠缺義務違反關聯性（最高法院 92 年度台上字第 4164 號判決參照）。乙之死亡並非甲所創造之酒駕或未開燈風險之實現，而是乙自己以極度危險之駕駛方式所招致，屬被害人自主危險之範疇，應由乙自我負責。

（四）若依實務所採之相當因果關係說：依一般經驗，正常行駛於自己車道之車輛，遭對向失控車輛越線撞擊，並非酒駕行為通常會導致之結果，二者間不具相當性。

（五）小結：乙之死亡不可歸責於甲，甲不成立刑法第 185 條之 3 第 3 項或第 2 項之致死罪；基於同一理由，亦不成立刑法第 276 條過失致死罪。至於甲自身之重傷，刑法不處罰自傷行為，無庸論罪。

三、競合

甲僅有一個酒後駕車之行為，僅成立刑法第 185 條之 3 第 1 項第 1 款不能安全駕駛罪一罪，無想像競合或數罪併罰之問題。

第三題（107 年地方政府特考三等）

甲無汽車駕照而駕駛汽車，某日超速而來不及剎車撞上對向車道違規左轉的機車騎士乙，造成乙死亡。事後確認，即使甲未超速，因為乙違規左轉又超速，甲仍然有高度可能性會撞上乙造成其死亡。請問甲的刑事責任為何？

【擬答】

甲撞死乙之行為，可能成立刑法第 276 條過失致死罪：

一、構成要件該當性

（一）甲對乙之死亡無知與欲，僅得審查過失犯。甲駕車撞擊乙，若無此行為乙不會死亡，二者間具條件關係。

（二）客觀注意義務之違反：1. 超速部分：甲超速行駛，違反道路交通法規所具體化之注意義務，創造法所不容許之風險。2. 無照駕駛部分：駕照制度係行政管制，目的在確保駕駛人具備基本駕駛能力；違反交通法規但未因此造成法所不容許之風險時，應否定其行為不法。本題並未顯示甲欠缺駕駛技術或因技術不足而肇事，故無照駕駛本身不足以作為本件過失之依據，僅生行政罰之問題。3. 甲自身超速，依前揭最高法院 84 年台上字第 5360 號原判例意旨，不得主張信賴原則。

（三）客觀迴避可能性（義務違反關聯性）：本題之爭點在於，事後確認即使甲未超速，因乙違規左轉又超速，甲「仍然有高度可能性」會撞上乙。此即學說上所謂「合法替代行為」之問題，學說有以下見解：

1. 風險升高理論：只要違反義務之行為，相較於合乎義務之行為，提高了結果發生之機率，即應歸責於行為人。依此說，甲之超速提高了撞擊風險，應予歸責。惟此說以機率高低論斷歸責，違反罪疑唯輕原則，且將過失實害犯變更為危險犯，不當擴大過失犯之處罰範圍，已為當前學說所揚棄。

2. 迴避可能性理論（本文採之）：須確定行為人若遵守注意義務即可避免結果，始具義務違反關聯性。若遵守注意義務時，結果幾近確定仍會發生，即屬客觀不可避免，欠缺結果不法（最高法院 92 年度台上字第 4164 號判決參照）；若遵守注意義務時，結果僅係「有可能」發生，學者認為因無法確定遵守義務即能避免結果，應本於罪疑唯輕原則，作有利於行為人之認定，否定義務違反關聯性。

3. 涵攝：本題即使甲未超速，仍有高度可能撞上乙致其死亡，無法確認甲遵守速限即可避免結果，乙之死亡在客觀上不可避免，欠缺結果不法，客觀上不可歸責於甲。

二、競合與結論

甲不成立刑法第 276 條過失致死罪；且過失犯不罰未遂，甲於刑法上不負刑事責任，既無任何犯罪成立，自無競合問題。至於甲無照駕駛及超速，僅生行政罰鍰之問題。